

1500367-29.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO VICTOR CUSTÓDIO DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

João Victor Custódio dos Santos, conhecido pela alcunha de "Gordinho", menor de 21 anos de idade, foi denunciado e está sendo processado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500367-29.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-29.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO VICTOR CUSTÓDIO DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

João Victor Custódio dos Santos, conhecido pela alcunha de "Gordinho", menor de 21 anos de idade, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 15h20min, na Rua João Dirolid, altura do nº 299, Jardim Zaniboni II, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de locais de trabalho coletivo e de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza, vendeu a Fábio Roberto Paulino 02 (duas)

porções de cocaína em forma de "crack", pesando aproximadamente 01g (um grama), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 108/122) e a denúncia foi recebida aos 07 de dezembro de 2021 (fls. 139/141).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu, sustentando que a prova é insuficiente para sua condenação e que o acusado sofria perseguição pelos policiais militares. No caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável, com incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, fixação de regime inicial aberto e afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, III da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 10), pelo laudo pericial do local (fls. 132/136); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 129/131) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar Magnon Gustavo Françoso disse que estava em patrulhamento pelo Jardim Zaniboni, ponto conhecido de venda de drogas, e avistou o acusado recebendo vinte reais de terceira pessoa. Realizou a abordagem e apreendeu o dinheiro com o acusado e duas pedras de 'crack' com aquela outra pessoa. O acusado informalmente disse que havia deixado o presídio recentemente e precisava de dinheiro. Disse que visualizou a troca entre o acusado e o outro indivíduo. Já havia abordado o acusado, mas nada ilícito apreendido anteriormente. Não conhecia a testemunha Fábio. Disse que a informação de tráfico no local persiste. Quando visualizou o contato entre o acusado e Fábio estava a dez metros de distância e eles não perceberam a aproximação da equipe. Realizou busca pelas imediações e nada apreendeu. Não esteve na casa do acusado. Disse que a abordagem ocorreu em frente a um bar, onde havia outras pessoas, que não compareceram à Delegacia de Polícia.

O policial militar Ronaldo Mendes da Silva prestou depoimento no mesmo sentido, confirmando que visualizou o contato entre o acusado e Fábio, sendo que este entrega cédula ao acusado, ao passo que João Vítor entregou objeto a Fábio.

Realizada a abordagem, apreendeu vinte reais com o acusado e duas pedras de 'crack' com Fábio. Visualizou que Fábio entregou uma cédula de vinte reais ao acusado.

Apenas após a busca pessoal verificou que Fábio portava as duas pedras de 'crack'. Ambos foram conduzidos à Delegacia. Soube que o irmão de João Vítor, de nome Matheus, encontrou Fábio dois dias depois e o ameaçou, caso prestasse testemunho em desfavor de João Vítor. Já havia abordado o acusado, mas nada ilícito apreendido. Não conhecia Fábio.

Fábio Roberto Paulino disse que é usuário de drogas e foi abordado na posse de duas pedras de 'crack' e as adquiriu de um rapaz de bicicleta. Nega que tenha adquirido do rapaz abordado e informa que conhecia o acusado de 'vista'. Nega que tenha dito que aguardava o acusado entregar as duas pedras de 'crack'. Disse que o acusado "queria ver as duas pedras", momento em que os policiais se aproximaram e viram que estavam próximos. Não sabe o motivo pelo qual o acusado trazia vinte reais com ele. Não entregou nada ao acusado. Os policiais disseram que "se o acusado não indicasse João, seria preso". Não leu o depoimento que constou na Delegacia de Polícia. Já esteve no mesmo local para adquirir droga e nunca viu o acusado naquele ponto.

Sílvia Custódio dos Santos é genitora do acusado e disse que ele havia saído de sua casa pouco tempo antes da abordagem. Disse que ele é usuário de maconha e 'crack' e sofre perseguição praticada pelos policiais.

Camila Tatiane Caetano da Silva disse que o conhece há muitos anos e nada sabe que o desabone. Sabe que ele é usuário de maconha e crack, este mais recentemente. Ele trabalhava como motoboy e sofria perseguição policial.

Em solo policial, o acusado João Victor Custódio dos Santos disse que foi ao local

para comprar uma pedra de crack e, pediu para ver a pedra que Fábio havia comprado, para saber "que tamanho estava". Porém, quando devolveu a pedra foi abordado pelos policiais. Sobre o dinheiro, informou que era de sua propriedade e que iria usar para comprar pedras (fls. 08).

Em juízo, o acusado disse que os fatos não são verdadeiros. Após retornar do trabalho, saiu para comprar droga e, ao chegar ao ponto de venda, encontrou a testemunha Fábio. Perguntou a Fábio onde estavam os "meninos" e ele lhe disse que haviam saído do local. O interrogando perguntou a Fábio se a porção de droga estava "servida" e Fábio lhe exibiu as pedras que havia adquirido. Nisso, os policiais se aproximaram e realizaram a abordagem. Nega que tenha recebido a cédula de vinte reais de Fábio e disse que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho. Era abordado com frequência por policiais militares. Não manuseou as duas pedras de 'crack' apreendidas com Fábio e disse que ele não estava parado no local, e sim andando.

Apesar da negativa do acusado, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão do relato prestado pelos policiais militares, que narraram que viram o momento em que o acusado recebeu uma cédula de vinte reais e entregou objeto à testemunha Fábio, seguindo abordagem e apreensão de porções de 'crack' com a testemunha Fábio e dinheiro com o acusado. Veja-se que a testemunha Fábio confirmou que estava no local para adquirir droga, embora, em juízo, tenha dito que não adquiriu as porções do acusado.

A esse respeito, vale destacar o depoimento do policial militar Ronaldo, que narrou que a própria testemunha Fábio lhe relatou ameaças praticadas pelo irmão do acusado, de nome Matheus, caso prestasse testemunho em desfavor de João Vitor. Nesse caso, embora Fábio tenha negado, na presente data, ter sido vítima de ameaças, tal negativa evidentemente se deve ao receio de sofrer mal injusto e grave, caso confirmasse a aquisição da droga junto ao acusado.

É por isso que, apesar da significativa alteração na versão apresentada por Fábio, o relato dos policiais militares confirmando o contato e troca de objetos entre Fábio e o acusado permite a condenação deste último, destacando-se que o policial Ronaldo foi seguro em afirmar que visualizou o momento em que Fábio entregou cédula de vinte reais ao acusado, recebendo objeto em troca.

De se pontuar que Fábio portava apenas as duas porções de 'crack', de modo que inequívoca a conclusão de que o entorpecente lhe foi entregue pelo acusado mediante pagamento de vinte reais.

O fato de nenhum objeto ilícito ter sido encontrado na posse do acusado não lhe socorre, na medida em que já havia feito a venda das duas pedras de 'crack' a Fábio, recebendo, por isso, a cédula de vinte reais apreendida pelos policiais militares.

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares, na medida em que o próprio acusado disse não se lembrar de ter sido anteriormente abordado por eles, assim como o documento de fls. 185/189 demonstra que a anterior prisão em flagrante do acusado foi realizada por policiais diversos.

Desse modo, não se vislumbra nenhum indício para os agentes imputarem falsamente o crime ao acusado, concluindo-se, pois, pela condenação.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos

do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I do Código Penal, sem reflexo sobre a pena-base, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide também a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de fls. 132/136 revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem praças públicas e campos de futebol, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que o estabelecimento de ensino seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro sua pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta diversos feitos registrados perante o Juízo da Infância e Juventude, inclusive com execução de medida socioeducativa (fls.27), o que demonstra que se dedica a atividades criminosas.

A esse respeito, o artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, não havendo previsão de que o envolvimento se refira apenas ao período da maioridade penal, o que permite concluir pela possibilidade de se considerar o tempo de inimizabilidade para avaliar se o réu faz jus às benesses daquele dispositivo. A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

"[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não

caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Se os antecedentes infracionais do agente não bastassem para o afastamento da causa de diminuição de pena, anoto que ele ostenta outro processo em andamento pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1504857-64.2021 - fls. 25) e foi beneficiado com a liberdade provisória no dia 25 de julho p.p., vale dizer, menos de 90 dias antes do fato aqui tratado.

Nem se diga que a inexistência de condenação criminal impede o afastamento do benefício na presente fase de dosimetria da pena, já que o artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, veda a redução da pena ao agente que se dedique a atividades criminosas, o que se pode dizer com segurança daquele que, menos de noventa dias após ser beneficiado com a liberdade provisória, torna a ser detido pela prática de tráfico de drogas.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pois a pena não ultrapassa o patamar de oito anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código

Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 – SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma) Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois superior a quatro anos.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO João Victor Custódio dos Santos à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que ostenta diversas anotações perante o Juízo da Infância e Juventude, inclusive com execução de medida sócioeducativa, e foi detido pelo fato aqui apurado menos de 90 dias após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro feito, o que indica que sua liberdade configura risco à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois não comprovada a origem lícita e porque se trata de consequência lógica da condenação imposta.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 26 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA